

1502958-57.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502958-57.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502958-57.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234045/2022 - 01º D.P. GUARUJA, FN6156-1/2022 - 01º D.P. GUARUJA, 2234045 - 01º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIAGO JESUS DOS PASSOS NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Hiago Jesus dos Passos Nascimento, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 07:33 horas, na Rua Osasco, altura do nº 103, Vila Áurea, nesta cidade e comarca de Guarujá, trazia consigo e guardava, para o fim de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 6 pedras de crack, derivado de cocaína, e em 4 porções de cocaína, substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; além do valor de R\$ 806,00 consoante o auto de constatação preliminar de fls. 7, o auto de exibição e apreensão de fls. 12 e as fotografias de fls. 18/20.

O réu foi notificado (fls. 74) e apresentou defesa prévia (fls. 77/79), que não

comportou acolhimento e a denúncia foi recebida (fls. 87/89). O réu foi citado (fls. 145).

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico-toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 114/116).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 155). E encerrada a instrução, pelas partes nada foi requerido, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 148).

O representante do Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 148/154).

Nos memoriais, a defesa requereu a improcedência da ação com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06 - em seu patamar máximo - a fixação do regime inicial aberto ou subsidiariamente o semiaberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 158/165).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1, pelo boletim de ocorrência de fls. 2/4, pelo auto de constatação preliminar de fls. 7, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, pelas fotografias de fls. 18/20, pelas imagens das body cams constantes do link de fls. 109, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 114/116, pelo BOPM de fls. 120/123, pelas imagens de fls. 124/127 - do momento em que o acusado dispensou no solo as drogas e o dinheiro - bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado na fase policial, o réu negou a prática delitiva. Relatou que na data dos fatos estava comprando uma "doleta" de maconha na Rua Osasco, em Vicente de Carvalho, de um indivíduo desconhecido, que costuma vender drogas nesse local. Utilizou uma nota de R\$ 100,00 para pagamento. Antes que recebesse a "doleta" de maconha, a Polícia chegou e o traficante correu, mas o interrogando permaneceu no local e foi preso. Não trazia consigo droga alguma, pois ainda não havia recebido a maconha que comprara. Tinha em sua mão, no momento da abordagem, o troco dos R\$ 100,00, que utilizara para comprar a droga, bem como mais R\$ 100,00 no bolso da bermuda, totalizando R\$ 195,00, e nada mais (fls. 10).

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática delitiva. Relatou que na data dos fatos foi comprar maconha, logo cedo, e utilizou uma nota de R\$ 100,00 para pagamento. No momento em que o traficante foi pegar o troco para o interrogando e pediu que o interrogando segurasse o maço de dinheiro para o traficante, a Polícia chegou. Todos correram, incluindo o interrogando, segurando o dinheiro que pertencia ao traficante, o qual foi dispensado no solo, enquanto o interrogando corria. Foi detido por um policial e outro policial entrou no interior do beco e voltou com um maço de cigarro contendo drogas. Desconhece de quem seja a droga apreendida pelo policial. Não sabe o motivo de estar sendo acusado da prática de tráfico de drogas pelos policiais. Não conhecia os policiais militares que participaram da operação, anteriormente aos fatos (fls. 155).

E a negativa do réu em juízo não restou afastada pelas demais provas produzidas nos autos, que demonstraram o inequívoco envolvimento do acusado no tráfico de drogas e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Carlos Magno Luz Lacerda, em seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos se encontrava em operação na Rua Osasco, Vila Áurea - conhecido ponto de tráfico de drogas e de roubo a caminhões. Algumas equipes fecharam as principais entradas dos muitos becos da região e outras adentraram nos becos. Quando o depoente e outros policiais iriam começar a incursão por

determinado beco (fotografia de fls. 124, que foi mostrada ao depoente na audiência), o interrogando e um indivíduo não identificado estavam correndo de outros policiais (fotografias de fls. 124/125). O interrogando veio para a direção do beco onde o depoente se encontrava e o segundo indivíduo foi para outra direção. Quando o interrogando percebeu que seria alcançado, dispensou um maço de cigarro contendo drogas em seu interior e certo valor em dinheiro, perto de R\$ 800,00 (fotografia de fls. 127). O depoente conseguiu deter o réu segurando-o por suas vestes (fotografia de fls. 126). O segundo indivíduo que estava na companhia do acusado conseguiu se evadir. O depoente não conhecia o acusado, anteriormente aos fatos. Reconheceu as fotografias de fls. 124/127, que lhe foram mostradas, como sendo das imagens captadas por sua body cam, no momento da detenção do acusado (fls. 155).

A testemunha Diogo Conrado Rodrigues, policial militar, em Juízo, relatou que na data dos fatos se encontrava em uma operação na Rua Osasco, Vila Áurea, conhecido ponto de tráfico de drogas. Os policiais militares se organizaram por equipes que se posicionaram nas entradas/saídas dos becos da região e por equipes que adentraram nos becos. Quando as viaturas policiais foram avistadas, alguns indivíduos correram pelos becos, na tentativa de fuga, dentre eles o acusado Hiago. Quem abordou o acusado não foi o depoente, o qual estava conduzindo a viatura policial e se encontrava em local diverso do local em que o acusado, quando de sua tentativa de fuga, foi alcançado. A equipe do depoente comunicou-se com a equipe que obteve êxito na detenção do acusado, e então as equipes se encontraram na entrada/saída do beco onde Hiago estava detido e aguardando para ser encaminhado ao Distrito Policial. O depoente não se recorda da versão dos fatos apresentada pelo acusado, nem quais drogas foram com ele apreendidas. Com o acusado foi encontrado um maço de cigarros com drogas e dinheiro, cerca de R\$ 800,00, que o depoente ajudou a contar (fls. 155).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição. A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, DJe. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]" (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Tem-se que diante do contexto em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do acusado, diante da forma de acondicionamento das drogas, do dinheiro em cédulas trocadas, e de todas as circunstâncias que culminaram com a abordagem e a prisão do acusado, que estava em local conhecido pela venda de drogas, restou comprovada a conduta típica narrada na inicial acusatória. Ressalte-se, ainda, que os relatos dos policiais militares foram corroborados pelas imagens gravadas através das câmeras corporais dos policiais que participaram da operação (link às fls. 109), e pelas fotografias de fls. 124/127, das imagens da câmera corporal do policial Carlos Magno Luz Lacerda.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o acusado trazia consigo e guardava os entorpecentes, e os entorpecentes eram destinados para a entrega a consumo de terceiros, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

E ainda, mesmo que o réu seja usuário de drogas, tal fato não afasta, necessariamente, a prática do delito de tráfico, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de substâncias entorpecentes para sustentarem o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

A propósito:

"(...) Ademais, a condição de usuário de drogas não exclui a de traficante, sendo, infelizmente, comum a mercancia realizada por usuários com o intuito de financiar seu vício (...)." (TJSP, Apelação nº 0000136-06.2016.8.26.0626, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Damião Cogan, julgado em 10/05/2019)

Nesse sentido, ainda:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade." (TJSP - HC 42.229-3 -Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498)

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, uma vez evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à entrega para consumo de terceiros.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, entendo que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, em relação à aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, verifico que o acusado preenche os requisitos legais, pois apresenta a condição de primário, não possui antecedentes (fls. 29/30, 31/32) e inexistem indícios de que integre organização criminosa. Destaco que embora o réu responda a outro processo pelo mesmo crime, o Tema Repetitivo nº 1139, do Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, o réu trazia consigo cocaína e crack (1,1g e 1,5g), que apesar do alto poder viciante, não foi em quantidade elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreram os fatos, a dedicação habitual do acusado à atividade criminosa, e que faz do tráfico de drogas um meio de vida. Tampouco se comprovou que o réu integra organização criminosa. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria penal aplico o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a reprimenda em 2/3, o que perfaz o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Torno definitivas as penas aplicadas.

Ausentes dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

Em relação ao regime prisional, considerando que o pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que "O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda." (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016), que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, modifico entendimento anterior e passo a entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não é crime equiparado a hediondo, de forma que o regime será fixado de acordo com o disposto nos artigos 33 e 59, do Código Penal.

Neste sentido, a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida"

(Pleno, HC nº 118.533, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 grifos da reprodução).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADO SEM OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA ESTABELECIDNA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO DEFERIDO, POIS PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que o paciente dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida - 2,71g de cocaína -, apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, a dedicação do acusado às atividades criminosas. - O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Hipótese em que o paciente é primário, condenado à pena não superior a 4 anos de reclusão, com análise favorável das circunstâncias judiciais, razão pela qual faz jus ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, do CP. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a sentença que fixou as penas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. (HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). E sendo assim, analisando os autos, tendo sido a reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Cumprir destacar que, apesar da Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não seria o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou da suspensão condicional da pena - nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal - pois não se mostram medidas suficientes e adequadas ao presente caso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Hiago Jesus dos Passos Nascimento para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e

ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, por incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

O acusado poderá recorrer em liberdade. E considerando que foi fixado o regime inicial aberto, entendo que a prisão do réu não mais se justifica. Expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado, nos termos da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial competente com a determinação de destruição da porção de droga reservada para eventual contraprova.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, vez que se trata de produto do tráfico de drogas. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para o cumprimento.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente a assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.

P.I.C.

Guaruja, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA